InDret
REVISTA PER A
L'ANALISI DEL DRET

WWW. INDRET.COM

La prelació entre el dret de representació i l'acreixement en la successió testamentària

Maurici Pérez Simeón

Facultat de Dret
Universitat Pompeu Fabra

BARCELONA, JULIOL 2008

Abstract[*]

L'art. 144.2 del Codi de Successions conferia en la successió testamentària un dret de representació als descendents del fill premort del testador. D'ençà l'entrada en vigor d'aquesta norma, ha estat polèmic en la doctrina si la crida dels descendents del premort ha de ser preferent a l'acreixement i/o a la substitució vulgar. En el rerefons del debat rau la qüestió del paper que les presumpcions legals han de tenir en la interpretació dels testaments.

L'art. 23-8 del Llibre Quart del CCC, aprovat mentre s'ultimava l'edició de l'article, inclou una regla similar a la de l'art. 144.2 del Codi de Successions, si bé el dret de representació no es limita expressament al cas de premoriència del fill instituït.

Section 144.2 of the Catalan Code of Succession provided that whenever a testator's beneficiary predeceased the testator, his issue should take his share. Since the Catalan Code of Succession entered into force, there has been an important debate among academics regarding whether the issue of a predeceased beneficiary should take before the other testator's beneficiaries in proportion to their shares and/or before the "vulgar substitution." The underlying debate is the role that legal presumptions should have for the interpretation of testamentary provisions.

Section 423-8 of the Catalan Civil Code's Book Four, recently approved, sets forth a similar provision, even though presenting new challenges regarding the scope of the above-mentioned rule and its judicial interpretation.

Title: Legal Rights vs. Will When Testator's Beneficiary Predeceases the Testator

Keywords: Law of Succession; Testate Succession; Predecease
Paraules Clau: Dret de Successions; Successió testada; Premoriència

---

[*] Aquest treball s'emmarca en el Projecte d'investigació "Autonomía e imperatividad en la ordenación de las relaciones familiares: los límites a la libertad contractual en la regulación de la convivencia y de sus crisis (SEJ 2005-08663-C02-02)", finançat pel Ministeri d'Educació i Ciència.

Sumari

1. La vocació de l'art. 144.2 del Codi de Successions
2. El litigi per l'herència de la Sra. Maria P.P.
2.1. L'origen del litigi i la Sentència del Jutjat de Primera Instància núm. 30 de Barcelona d'1.2.2005
2.2. El recurs d'apel·lació i la Sentència de l'Audiència Provincial de 10.10.2006
2.3. El recurs de cassació i la Sentència del Tribunal de Justícia de Catalunya de 26.7.2007
3. Anàlisi de la qüestió jurídica controvertida: la prevalença de la crida del testador enfront el dret legal de representació
3.1. La voluntat testamentària presumpta a l'art. 144.2 CS
3.2. L'expressió *"amb dret d'acréixer"* en el testament
3.3. La prelació entre la voluntat testamentària presumpta de l'art. 144.2 CS i l'acreixement ordenat pel testador de forma expressa o tàcita
a) Sentit i abast de l'expressió *"Llevat que aparegui que és una altra la voluntat del testador..."* de l'art. 144 CS
b) L'art. 144.2 CS i l'acreixement entre hereus instituïts conjuntament
c) L'art. 144.2 CS i l'acreixement entre hereus als quals el testador ha atribuït expressament el *ius adcrescendi*
4. Conclusions
5. Apèndix: les novetats en la regulació del problema en el Llibre Quart del Codi civil de Catalunya
6. Jurisprudència citada
7. Bibliografia

1. *La vocació de l'art. 144.2 del Codi de Successions*

És sabut que l'objectiu de moltes de les regles de la Compilació catalana (Llei 40/1960, de 21 de juliol; BOE núm. 175, de 22.07.1960) i de les normes posteriors en matèria de Dret successori va ser posar fi per decisió legislativa a controvèrsies seculars heretades de la tradició del *ius comune*. Amb això es pretenia crear seguretat jurídica en els testadors i reduir la litigiositat.

En ocasions, però, el legislador, tot intentant acabar amb una controvèrsia secular, inadvertidament n'obre una altra. Aquest és el cas de l'art. 144.2 del *Codi de successions per causa de mort en el dret civil de Catalunya (Llei catalana 40/1991, de 30 de desembre; DOGC núm. 1544, de 21.1.1992. Correcció d'errates en el DOGC núm. 1582, de 13.4.1992, i en el DOGC núm. 1600, de 29.5.1992; en endavant, CS)*. Aquesta norma prescriu que, si el testador institueix als seus fills nominativament i per parts iguals, han de reputar-se cridats també a succeir els descendents dels instituïts per estirps. Aquesta regla acaba amb una llarga controvèrsia sobre si resulta transportable a la successió testada el dret de representació que el Dret romà-justinianeu regulava expressament només per a la successió testamentària, però crea un altre problema de gran importància pràctica: la crida dels descendents dels instituïts, és preferent a la substitució vulgar o a l'acreixement?

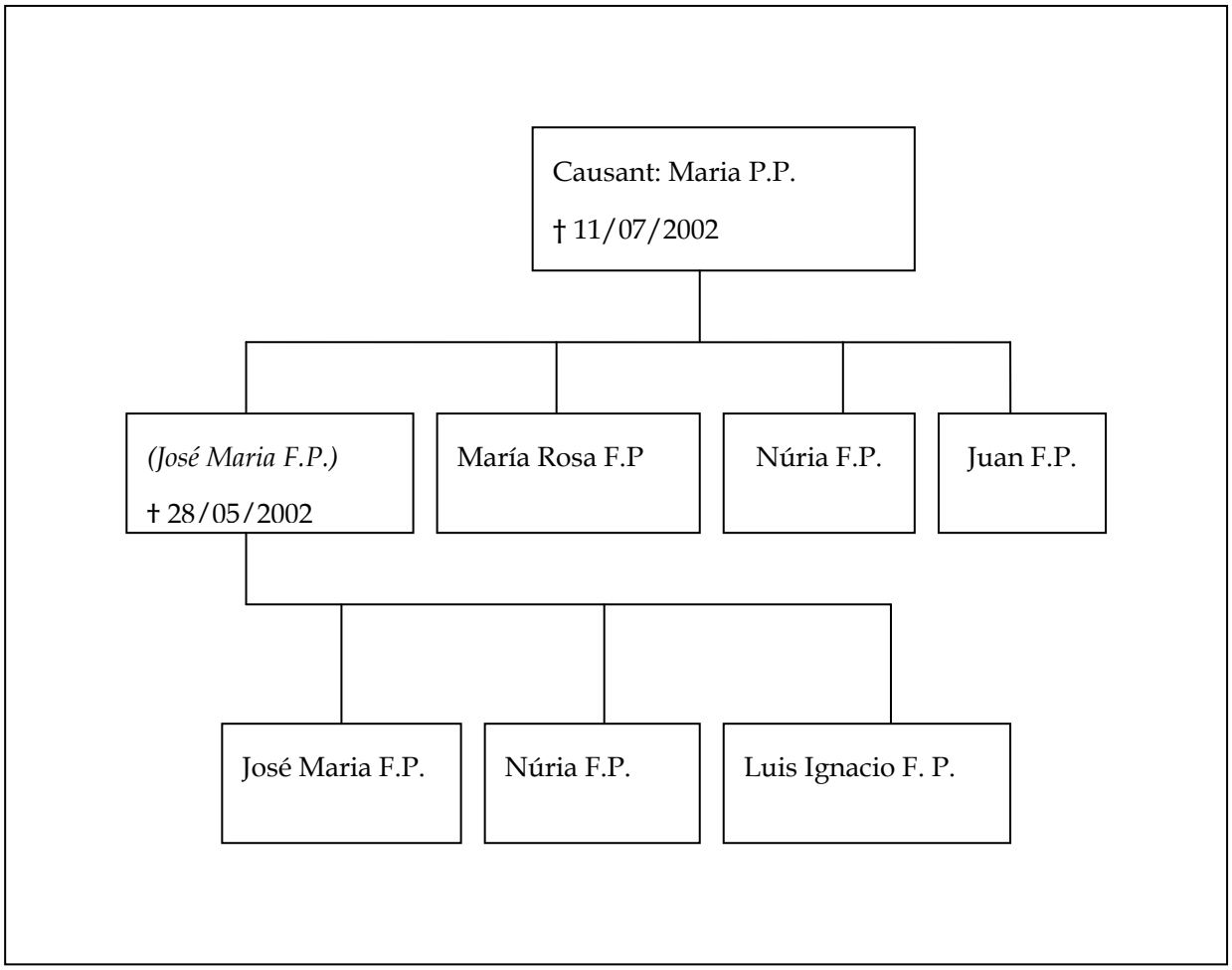
2. *El litigi per l'herència de la Sra. Maria P.P.*

Un cas molt interessant plantejat recentment ha obligat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a posicionar-se sobre aquesta qüestió. Els fets no presenten excessiva complexitat: el dia 23 d'abril de 2001, la Sra. Maria P.P., de veïnatge civil català, havia atorgat el seu últim i vàlid testament, en forma de testament notarial obert, instituint hereus als seus quatre fills amb les paraules següents:

> "*Institueix hereus universals i lliures de tots els seus béns, drets i accions, presents i futurs, als seus quatre fills senyors Josep Maria, Maria Rosa, Núria i Joan F. P., amb dret d'acréixer, amb les següents NORMES PARTICIONALS...*"

Seguien en el testament una sèrie de normes particionals relatives a l'únic bé de l'herència: una casa pairal situada en el terme municipal d'Avinyó (Barcelona), que incloïen la designació de les filles de la testadora Maria Rosa F. P. i Núria F.P. com a marmessores particulars; en la clàusula segona, la testadora establia un dret d'adquisició preferent dels hereus instituïts, pel cas que algun d'ells vengués la seva part en la finca que constituïa l'únic actiu hereditari; en la clàusula tercera la testadora prohibia qualsevol judici de testamentaria i, en la quarta, establia l'anomenada cautela Socini, a l'empara d'allò previst en l'art. 360.2 CS.

El dia 28 de maig de 2002 va morir un dels hereus instituïts en el testament, el senyor José Maria F.P., deixant tres fills, el senyor José Maria, la senyora Núria i el senyor Luis Ignacio F.C. Pocs dies després, concretament l'11 de juliol de 2002, va morir la testadora.



El dia 13 de setembre de 2002, els tres fills supervivents de la testadora van atorgar escriptura pública d'acceptació d'herència com a únics hereus, repartint-se per terceres parts l'haver hereditari, en considerar que la premoriència del quart germà instituït (José Maria F.P.) l'havia exclòs de la successió, ja que s'havia ordenat al testament un dret d'acréixer. El 30 de gener de 2003, un dels tres hereus, Juan F.P., va vendre la seva part sobre l'únic actiu de l'herència, consistent en una part indivisa de la *casa pairal* situada a Avinyó (Barcelona), a la seva neboda la senyora Cristina R.F., i al marit d'aquesta, el Sr. Alejandro V.L.E. Tant l'acceptació d'herència com la venda foren inscrites en el Registre de la Propietat.

2.1. L'origen del litigi i la Sentència del Jutjat de Primera Instància núm. 30 de Barcelona d'1.2.2005

Els tres fills de l'instituït premort, que posseïen materialment una part de la *casa pairal* d'Avinyó, es van negar a acceptar el repartiment hereditari referit anteriorment, en considerar que l'art. 144.2 CS els donava dret a ocupar en l'herència de la seva àvia el lloc que hauria correspost al seu pare premort. Per això van interposar demanda de petició d'herència contra els tres instituïts supervivents que s'havien repartit tota l'herència i també contra la senyora Cristina R.F. i el senyor Alejandro V.L.E. com a tercers adquirents d'una tercera part de l'únic actiu de l'herència.

Els demandats van formular demanda reconvencional sol·licitant el lliurament possessori de la part de la finca que encara ocupaven els actors.

La demanda va correspondre en repartiment al Jutjat de Primera Instància núm. 30 de Barcelona. La Magistrada Substituta Sra. Teresa Maria Ramos Ibós va dictar sentència el dia 1 de febrer de 2005 (núm. 36/2005), estimant la demanda i desestimant la reconvenció. Els seus arguments es resumeixen en els següents paràgrafs del Fonament Jurídic segon:

> "La cuestión que se plantea es si tal interpretación unilateral de los herederos sin la intervención de los hijos del heredero premuerto es válida. La solución, en opinión de quien juzga, debe ser negativa. En efecto, el artículo 144 CS introdujo un derecho de representación en la sucesión testada, aunque técnicamente es más bien un supuesto de sustitución vulgar tácita: así en el caso de institución genérica a favor de los hijos o nominativamente pero a favor de todos ellos, se incluirá en el llamamiento a los hijos de los que hubieran premuerto. La aplicación de esta norma lleva a considerar que los hijos del fallecido ocuparán su lugar en la sucesión del causante señalado. Dicha regla se aplicará salvo que sea otra la voluntad del testador. La interpretación que todos los interesados en la sucesión efectúan debe prevalecer sobre la norma legal. Ahora bien, en el supuesto de autos no intervienen todos los interesados en la sucesión en la fijación de la voluntad de la testadora. Resulta intrascendente a tales efectos si se incluyó expresamente el derecho de acrecer en el testamento. Tal cláusula ni quita ni añade nada, pues se trata de una cláusula legal que opera de forma automática salvo que se excluya expresamente, por lo que no puede suponer de inmediato la exclusión de los hijos del heredero premuerto. La interpretación de la voluntad del testador debe hacerse por todos los interesados en la sucesión, incluso los beneficiados por la aplicación de la regla del artículo 144 CS. Al no haber intervenido los mismos, la solución debe estar a favor de la aplicación de la regla señalada (nunca podrá interpretarse la voluntad del causante contra una norma legal sin consentimiento de los favorecidos de la misma). De otro modo, dicha regla prevista en el artículo 144,2 CS, nueva en el derecho catalán y que difiere del sistema del Derecho común, quedaría sin sentido y vacía de contenido, bastaría la aplicación del derecho de acrecer para excluir a los hijos del heredero premuerto en cualquier caso. La aplicación del derecho de acrecer precisa de una vacante, cuya existencia debe examinarse teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 144,2 CS.
>
> Consecuencia de lo anterior es la estimación de la demanda, pues al estimarse que debían haber intervenido en la fijación de la voluntad de la testadora todos los interesados en la sucesión, y existiendo controversia entre ellos, habrá que estar a la regla de interpretación legal del testamento, pues habiendo instituido Doña María P. herederos por partes iguales a sus cuatro hijos y habiendo premuerto uno de ellos, corresponde a los hijos de éste, nietos del causante, suceder a su abuela en la parte de su padre, conforme al artículo 144 del Código de Sucesiones de Cataluña.
>
> En virtud de lo expuesto y razonado, debe estimarse íntegramente la demanda con

> desestimación íntegra de la demanda reconvencional, pues la nulidad de la compraventa formalizada entre Don Juan F.P. y Doña Cristina F. y Don Manuel Alejandro V. L.-E. es consecuencia necesaria de cuanto queda dicho, máxime cuando la situación de controversia entre los nietos aquí actores y los vendedores demandados era notoria en la familia sin que pueda pretenderse un presunto desconocimiento de tal situación por los demandados en que amparar la bondad de la compraventa".

Sorprèn realment la regla interpretativa que ens proposa la sentència, segons la qual, de mutu acord, els drethavents poden *"fijar la voluntad de la testadora"*, això és, poden interpretar com vulguin el testament, sigui quina sigui la veritable intenció del testador. El nostre dret no coneix una regla com aquesta. Al meu parer, la Sentència confon l'acord sobre el repartiment dels béns hereditaris i la interpretació del testament. El primer sí que queda a l'arbitri dels drethavents (sempre que respectin els drets de tercers), el segon no. Una altra cosa és que, si cap dels drethavents suscita polèmica arran d'una interpretació del testament, de *facto*, cap Tribunal podrà arribar a pronunciar-se sobre el particular, per molt aberrant que sigui la interpretació consensuada. Però això no implica que les facultats d'interpretació corresponguin als drethavents de comú acord i, en especial, no pot compartir-se la frase: "mai podrà interpretar-se la voluntat del causant contra una norma legal sense consentiment dels afavorits de la mateixa". La successió testada es regeix per la voluntat del testador, no per les disposicions legals ni per la voluntat dels drethavents. La voluntat del testador – sens perjudici de les normes imperatives – ha de prevaler sempre i els Tribunals són els garants d'aquesta prevalença.

Al marge d'aquesta regla interpretativa tan *sui generis*, la resolució estimatòria de la demanda es fonamenta també en la consideració que el dret d'acréixer ordenat expressament per la testadora no és més que una reiteració innecessària del règim legal. La Sentència ho deixa ben clar: "*tal cláusula ni quita ni añade nada*". En altres paraules: el dret de representació de l'art. 144.2 CS seria preferent a qualsevol acreixement, tant el que es fonamenta en una disposició expressa del testador com el que prové de la seva voluntat tàcita manifestada a través de la institució conjunta. Pel que fa a la compravenda, l'anul·lació es basa en una apreciació de mala fe en els compradors, que la Sentència considera provada pel mer fet d'estar emparentats amb el venedor.

2.2. El recurs d'apel·lació i la Sentència de l'Audiència Provincial de 10.10.2006

La Sentència de Primera Instància va ser apel·lada i l'Audiència Provincial de Barcelona (Civil Sec. 1a), en una resolució de 10 d'octubre de 2006 que ha estat publicada (JUR 2007\145197), va confirmar l'estimació de la demanda, declarant que els fills de l'instituït premort tenien dret a participar en la successió en el lloc del seu pare en virtut de l'art. 144.2 CS. No obstant això, a diferència del Jutjat, l'Audiència va considerar que l'adquisició dels compradors – Sra. Cristina R.F. i Sr. Alejandro V.L.E. – havia de mantenir-se a l'empara de l'art. 34 de la Llei Hipotecària. No entraré aquí a analitzar amb detall l'aplicació que fa la Sentència d'aquest últim precepte, ja que ens allunyaria de la qüestió doctrinal relativa a l'acreixement. Només cal dir que l'Audiència va tenir una posició especialment tuïtiva dels tercers adquirents, negant-se a apreciar la mala fe dels adquirents únicament pel mer fet que existís un vincle de parentiu entre ells i el venedor.

El ponent d'aquesta Sentència va ser el professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i Magistrat Suplent Josep Llobet Aguado, que va dictar la sentència juntament amb les Magistrades la senyora Maria Dolors Portella Lluch, Presidenta de la Secció 1a, i la senyora Laura Pérez de Lazárraga Vilanova. Encara que no estic d'acord amb el sentit de la resolució, he d'admetre que està molt meditada i molt ben argumentada.

El raonament de la sentència consisteix en considerar aplicable al cas l'art. 144.2 CS[1] i després analitzar la voluntat de la testadora a fi de descobrir si va voler excloure als seus néts de la successió. La sentència admet que l'únic argument a favor d'aquesta interpretació és l'expressió "*amb dret d'acrèixer*" que la testadora va incloure en el seu testament però la considera insuficient. Segons la sentència:

> "(…) no puede establecerse sin más una sinonimia entre la expresión "con derecho de acrecer" y el efecto expulsivo de los nietos de una sucesión. Para que este efecto se diese, nada más fácil que establecerlo y disponerlo expresamente para que tan trascendental efecto no quedase al albur de particulares interpretaciones. Para que se dé el derecho de acrecer, resulta inexcusable que se cumplan los requisitos que con carácter general establece el art. 38 CS (institución conjunta, que alguna cuota quede vacante, que el testador no lo prohíba), explicando el art. 39 CS lo que debe entenderse por institución conjunta, y clarificando el art. 40.3 CS que no debe entenderse vacante una cuota si opera el *ius transmissionis* o la sustitución vulgar o fideicomisaria, salva voluntad contraria del causante. Por tanto, la voluntad del causante, en relación con el derecho de acrecer tiene su trascendencia en cuanto que, pese a la concurrencia de los requisitos legales, lo puede excluir (arts. 38.1 y 40.3 CS). También tiene su trascendencia cuando, pese a no concurrir el requisito legal de la institución conjunta, el causante puede conceder el derecho de acrecer (art. 39.2 CS: "salvo que el testador conceda el derecho de acrecer, este no tiene lugar si en otra cláusula asigna individualmente a cada heredero una parte alícuota, y tampoco si el heredero no llega a serlo por nulidad o por revocación de la institución"). Pues bien, ninguno de estos casos en que la voluntad del testador tiene relevancia en la configuración del derecho de acrecer se acomoda al supuesto de autos (ni la testadora lo prohíbe, ni lo puede conceder ya que no ha asignado individualmente a cada heredero una parte alícuota ni existe nulidad ni revocación de la institución).
>
> (b) Se ha apuntado que la conclusión a la que llegan los demandados en el sentido de que la expresión testamentaria "con derecho de acrecer" significa que la testadora quería excluir a sus nietos de su sucesión no se ve avalada por los actos anteriores, coetáneos ni posteriores al otorgamiento, los cuales, como se ha dicho, deben tenerse sin duda en cuenta por constituir un dato de especial relevancia para establecer la voluntad del

[1] La Sentència també examina, per a descartar-la, la possibilitat de considerar que no s'hagin assignat parts iguals als hereus perquè les normes particionals establertes per la pròpia testadora assignen una part concreta i desigual de la finca que constitueix l'únic actiu hereditari a cadascún dels instituïts. Amb encert, la Sentència conclou que l'existència d'aquestes normes particionals no afecten a la igualtat en les quotes hereditàries.

> testador al tiempo del otorgamiento. Los actos de la testadora que constan en los autos, admitidos por ambas partes, y que revisten trascendencia al respecto son, básicamente, la actitud de tolerancia y consentimiento a que tanto el hijo premuerto de la causante, D. José María F. P., como los hijos de éste, nietos de la causante y actores principales en este procedimiento, residiesen habitualmente en la parte de la finca que, según las normas particionales establecidas por la causante, debía ser adjudicada a D. José María F. P. Esta realidad posesoria existía con anterioridad al otorgamiento del último y válido testamento de la causante y continuó después sin que conste acto obstativo ninguno por la testadora. En la misma dirección puede interpretarse el hecho de que tanto D. José María F. P. y sus hijos realizasen continuos actos de administración en relación a la referida finca (f. 354 a 430 de las actuaciones, consistentes en abundante documental, constando, entre otros, recibos por el arriendo de tierras de cultivo, gestiones realizadas ante la administración municipal y estatal, pagos de impuestos, gestiones ante compañía aseguradora consecuencia de un siniestro..., constando incluso –f. 424- una autorización de la causante a favor de su hijo D. José María F. P. para que realizase ante el Catastro cualquier gestión relacionada con la finca).
>
> En función de lo expuesto, no puede concluirse que la voluntad de la causante fuese excluir a sus nietos de su sucesión ni se dan los requisitos legales para que ello pueda suceder…".

L'Audiència, en els fons, ve a argumentar que l'expressió *"amb dret d'acréixer"*, interpretada de conformitat amb l'actitud pública de la testadora durant la seva vida, no sembla expressar una voluntat d'excloure als néts de la successió i per això considera que han d'entrar a succeir per dret de representació els fills de l'instituït premort. No podem entrar aquí a apreciar si els mitjans de prova obrants van ser valorats correctament o no, ja que nosaltres no els hem tingut tots a la nostra disposició. Sí es pot dir, però, que l'argumentació de l'Audiència resulta insuficient.

Si les paraules *"amb dret d'acréixer"* no es van expressar per anteposar els fills enfront dels néts, per què les va utilitzar la testadora? La resolució de l'Audiència no ho diu i aquest és, al meu parer, el seu principal punt feble. Costa d'admetre que en un acte solemne com un testament notarial obert una testadora inclogui una expressió tècnica com aquesta sense cap finalitat. En altres paraules: no sembla raonable tenir per no posada en un testament una clàusula fonamental com la que ens ocupa únicament sobre la base que el comportament públic de la testadora en vida no permet constatar una enemistat entre la testadora i els néts perjudicats per l'acreixement. Potser seria el primer cas en què un testador dissimula en vida el sentit de les seves disposicions testamentàries a fi de no guanyar-se l'enemistat d'un parent? D'altra banda, decantar-se per la primacia de l'acreixement implica interpretar que la testadora va voler que, si hi havia fills vius (qualsevol fill), aquests succeïssin per davant dels néts (qualsevol nét). L'amistat o enemistat de la testadora amb un fill o amb un nét concret resultarien potser un argument vàlid per interpretar una clàusula que es referís específicament a ell, però no pot servir per interpretar una clàusula d'abast general com la que estem examinant.

2.3. El recurs de cassació i la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 26.7.2007

Els fills que havien sobreviscut a la testadora i els tercers adquirents van recórrer en cassació davant el TSJC i van tenir èxit. La Sentència del TSJC de data 26 de juliol de 2007 va desestimar totalment la demanda dels fills de l'instituït premort i va estimar totalment la demanda reconvencional. El punt essencial en què la Sentència del TSJC fonamenta la seva resolució és que (FD 8è):

> *"No ens trobem en aquest cas davant de dues voluntats presumptes o probables del testador que obliguin a escollir entre la previsió de l'article 38 o la de la l'article 144 sinó davant la voluntat clara i expressada, contrària a la crida dels néts".*

A més a més, el TSJC ens diu (FD 9è) que:

> *"(…) la Sala d'apel·lació ha infringit l'article 144 del Codi de successions, ja que en el cas consta la voluntat contrària de la causant. Mentre ens moguem davant d'elements d'integració considerats per la llei pressuposant quina seria la voluntat del testador, podem parlar d'inexistència de quota vacant als efectes d'excloure el dret d'acréixer quan es crida els fills genèricament o els fills nominativament en parts iguals, però entre la presumpció de voluntat del testador de l'article 144.2 i la determinació expressa del dret d'acréixer en el testament ha de prevaldre aquest últim".*

La Sentència del TSJC coincideix amb els arguments esgrimits per la defensa dels demandats que es basaven, en essència, en el dictamen que jo mateix havia elaborat al seu requeriment, en la meva condició de professor a la Universitat Pompeu Fabra, el dia 10 d'octubre de 2003, abans que s'iniciés la controvèrsia judicial.

3. Anàlisi de la qüestió jurídica controvertida: la prevalença de la crida del testador enfront el dret legal de representació

Com hem vist, la clau de la controvèrsia plantejada consistia en determinar si els descendents del fill premort de la testadora tenien dret a succeir en virtut de l'art. 144.2 CS, o bé si la quota deixada vacant per premoriència corresponia als altres tres fills de la testadora instituïts nominativament en el testament amb dret d'acréixer.

Al meu parer, la resolució de les qüestions plantejades requereix resoldre dos problemes diversos que, si bé es complementen, requereixen un tractament separat. D'una banda tenim la qüestió, de caràcter general, consistent a determinar si l'acreixement ordenat expressament per la testadora opera de forma preferent a la crida dels néts i ulteriors descendents que preveu l'art. 144.2 CS, o bé si a l'inrevés. Les conclusions a què arribem han de ser aplicables a qualsevol testament en què els hereus instituïts tinguin concedit, expressa o tàcitament, el dret d'acréixer.

El segon lloc, hem de procedir a un examen global del testament de la Sra. Maria P.P. per decidir si, en aquest testament concret, hi ha elements suficients per a interpretar que la testadora va voler excloure l'aplicació de l'art. 144.2 CS, el qual, per expressa indicació legal, només opera "*llevat que aparegui que és una altra la voluntat del testador...*". Les conclusions d'aquest examen només es referiran al testament concret objecte d'estudi.

3.1. La voluntat testamentària presumpta en el art. 144.2 CS

L'article 144 CS té el tenor següent:

> "Llevat que aparegui que és una altra la voluntat del testador si aquest crida els seus hereus i legataris o llurs substituts sense designació de noms i mitjançant l'expressió "fills" s'entenen inclosos en aquesta denominació tots els fills matrimonials, no matrimonials i adoptats, homes i dones, i els néts i els descendents els pares respectius dels quals hagin mort abans de la delació, excloent el grau més pròxim al més remot i entrant per estirps els del grau següent en lloc dels de grau anterior. S'aplica la mateixa regla en el cas que els fills siguin designats nominativament per parts iguals".

Aquest article conté dues regles completament diverses. En la primera oració ("*Llevat (...) anterior*") ens trobem davant una norma interpretativa del terme genèric "*fills*". Aquesta regla no fa una altra cosa que donar primacia, en la interpretació del testament, a un dels diversos sentits que pot tenir aquesta paraula, concretament, el sentit més extensiu, que inclou els descendents de qualsevol sexe, condició i grau. Als descendents de tercer i ulterior grau se'ls té per cridats tàcitament a succeir per estirps, en el lloc dels seus ascendents premorts.

Aquesta regla interpretativa no ens concerneix ara, ja que en el testament de la Sra. Maria P.P. no es va fer una referència genèrica als fills, sinó que se'ls va instituir cridant-los pels seus noms. Ens interessa per tant, la frase final del precepte, segons la qual:

> "*S'aplica la mateixa regla en el cas que els fills siguin designats nominativament per parts iguals*".

Aquesta norma fou introduïda per primera vegada en el Dret català pel CS, ja que l'antic art. 114 de la Compilació contenia tan sols la regla interpretativa per al cas que el testador hagués emprat el terme genèric "*fills*" per instituir hereus o designar legataris.

Encara que la norma remeti al primer incís de l'art. 144 CS, en realitat està introduint una regla de naturalesa i abast completament diferent a la d'aquell primer incís. No estem aquí davant d'una regla interpretativa, que escull entre un dels diversos sentits que poden tenir les paraules utilitzades pel testador, sinó que ens trobem davant d'un precepte que complementa el que s'ha dit pel testador amb una voluntat que li presumeix. No pretén aquesta regla, per tant, revelar una voluntat tàcita, que el testador va deixar implícita en els termes genèrics que va utilitzar (com era el cas en la interpretació de "*fills*"), sinó que, sense que existeixi en el testament cap element que permeti intuir, encara que sigui de forma incompleta, la voluntat del testador, la Llei completa una disposició testamentària perquè presumeix que el testador va ometre dir quelcom que en realitat volia.

En altres paraules: les normes interpretatives de la voluntat testamentària pretenen guiar a l'exegeta primant un dels diversos sentits que pot tenir l'expressió utilitzada pel testador. A banda del cas ja vist en el primer incís de l'art. 144 CS, són també normes interpretatives l'art. 145 CS (per a les expressions "*hereus meus*", "*hereus legítims*", "*hereus intestats*", "*parents mes pròxims*", "*parents*", "*successors*", "*aquells a qui per dret correspongui*", "*els meus*"), l'art. 142 CS (per a la institució d'una persona "*i els seus fills*"), l'art. 166 CS (per a l'eficàcia de les prohibicions de disposar sotmeses a autorització d'un tercer), etc. En tots aquests casos, la Llei escull aquell sentit de l'expressió utilitzada que amb major probabilitat s'ajusta al que vol el testador prototípic. Ens trobem, per tant, davant d'una voluntat testamentària tàcita.

Al contrari, la funció de les normes presumptives de la voluntat testamentària és complementar *ex lege* unes disposicions testamentàries que el legislador considera típicament incompletes; el complement es considera oportú perquè són casos en què, en opinió del legislador, el testador sol expressar-se incorrectament, generalment perquè anomena una espècie quan en realitat vol indicar un gènere. És una norma d'aquest tipus l'art. 167.2 CS, segons el qual la substitució vulgar ordenada per al cas de premoriència o per al cas que el substituït no pugui o no vulgui succeir, s'entén ordenada també per als altres casos en què el substituït quedi apartat de la successió. Per tant, si el testador va dir "Si A premor, sigui B el meu hereu" ha de considerar-se que va voler dir "Si A premor «o per qualsevol altra causa no pot o no vol succeir», sigui B el meu hereu". És obvi que, en aquest cas, la Llei no es limita a interpretar, sinó que complementa, ja que és insostenible que l'expressió «o per qualsevol altra causa no pot o no vol succeir» estigui implícita en els termes elegits pel testador.

El mateix succeeix amb l'últim incís de l'art. 144 CS: la Llei ens diu que si el testador va dir "Institueixo hereus als meus quatre fills, A, B, C y D", s'ha d'entendre que afegeix «i als seus respectius descendents per estirps, segons les normes de dret de representació». En aquest cas, a diferència del que succeeix amb la primera oració de l'art. 144 CS, no es pot sostenir que la llei reveli quelcom que estava implícit en les paraules del testador: es pot interpretar que sota el terme genèric *"fills"* s'engloben tots els descendents, instituïts per estirps, però no és admissible interpretar que quan el testador va instituir a quatre hereus cridant-los pels seus noms específics, obviant tota ambigüitat, en realitat va voler instituir a aquests quatre i als seus respectius descendents per estirps. El que pot fer la Llei – i és el que, de fet, fa – és assumir que, de vegades, qui institueix als seus fills nominativament, no esmenta els ulteriors descendents per oblit, de manera que pot ser útil a vegades complementar per ministeri de la llei el que s'ha dit pel testador. La Llei actua com a complement, no com a intèrpret.

Aquest tipus de normes tenen el seu origen en la ciència jurídica medieval, que tendeix a convertir en regles interpretatives generals el que havien estat decisions sobre casos concrets en el Dret romà. El gust de la jurisprudència medieval per la creació de normes presumptives de la voluntat testamentària arriba a crear un corpus de regles, moltes de les quals esdevenen clàssiques en l'edat moderna [vegeu, per exemple, Antonio GÓMEZ (1768), part.1, cap. 3 n.10, Jacobo CUYACIO (1758), lib. 8, *ad* D.35,1,101, Paulus BUSIUS (1656), *ad* D.28,6,1 n.3, E. ZOES (1718), *ad* D.28,6 n.7, Dominik VAN ARUM (1620), disp. 17, thes. 17 i Christian THOMASIUS (1766), tom 3,

comentari a D.28,6, n.1). tots ells en relació amb la regla relativa a la substitució vulgar amb *condicio substitutionis* incompleta] i també en la pandectística alemanya del s. XIX [per tots, B. WINDSCHEID i Th. KIPP (1906) § 557 [p. 277] i § 562 [p. 291]]. Algunes d'aquestes regles han sobreviscut al procés codificador i s'han incorporat a les vigents normatives civils, com, per exemple, el § 2097 BGB.

La naturalesa jurídica de la regla continguda en l'art. 144.2 CS no és l'únic problema que planteja aquesta norma. Hi ha una polèmica entre els civilistes sobre si el dret a succeir que introdueix el segon incís de l'art. 144 CS ha de configurar-se com una substitució vulgar presumpta o com un dret de representació operatiu en l'àmbit de la successió testamentària.

La primera postura ha estat sostinguda per algun autor (CALATAYUD SIERRA, 1994, pp. 658 i 670) però ha tingut poca acceptació en la doctrina. L'opinió que es pot tenir per dominant (vegeu, per tots, RUBIES MALLOL, 1994, p. 549, i BOSCH CAPDEVILA[2], 2002, p. 275) és la segona: l'art. 144 CS introdueix un dret de representació operatiu *ex lege* en la successió testamentària.

RUBIES MALLOL i BOSCH CAPDEVILA fonamenten aquesta postura majoritària en sòlids i convincents arguments:

a) El preàmbul del CS diu que l'art. 144 CS "introdueix el dret de representació en la successió testada en el supòsit d'institució genèrica de fills o de la institució nominada i sense parts de tots els fills".

b) L'art. 144 CS només opera en cas de premoriència, igual que el dret de representació, mentre que la substitució vulgar opera si l'instituït no vol o no pot succeir, tret que el testador hagi restringit la seva eficàcia a un supòsit determinat (art. 167 CS).

c) L'art. 144 CS opera tant si el premort ha mort abans de l'atorgament del testament com si ho ha fet després, ja que es diu només "hagin mort abans de la delació"; si fos una substitució vulgar, podria operar tan sols si el substituït hagués mort després de l'atorgament del testament, ja que és un pressupost de la substitució vulgar que existeixi una crida testamentària que quedi frustrada.

Jo també opino que el dret de l'art. 144 CS s'ha de concebir com un dret de representació que opera en la successió testamentària. De totes maneres, convé analitzar també les conseqüències que comportaria per al nostre cas acceptar la tesi contrària.

[2] Aquesta obra, que és la reelaboració de la tesi doctoral d'aquest brillant civilista, constitueix l'únic estudi exhaustiu del tema existent en Dret català; tot i que no subscric alguns dels punts de vista que l'autor defensa en el seu treball, no hi ha dubte de què el llibre constitueix el punt de referència obligat en qualsevol estudi referent a l'acreixement en el CS.

Tant si es configura el dret a succeir establert en el segon incís de l'art. 144 CS com un dret de representació com si es veu en ell una substitució vulgar, queda fora de la controvèrsia el fet que la delació que reben els néts i ulteriors descendents prové de la llei i no del testament. En paraules de BOSCH CAPDEVILA (2002, p. 276[3]): "*Tot i que hi ha hagut una declaració de voluntat instituint els fills, la crida a l'estirp no la fa el testador, que és limita a cridar els fills, sinó la Llei*".

Aquest fet resulta fonamental per a enquadrar el dret a succeir dels néts i ulteriors descendents que concedeix el segon incís de l'art. 144 CS en el marc de la successió testamentària: la vocació legal *ex* art. 144 CS queda exclosa en tot cas si hi ha una vocació testamentària vàlida i eficaç, no sols perquè així ho estableixi el propi art. 144 CS en les seves paraules inicials ("*Llevat que aparegui que és una altra la voluntat del testador*...") sinó també perquè la primacia de la successió voluntària enfront de la legal és un dels principis fonamentals del Dret successori català, en el Preàmbul del qual (apartat II) se'ns diu:

> "*No es modifiquen, per tant, els grans principis propis del Dret Romà, tan arrelats en el Dret successori català.* [...] *El principi de prevalença del títol voluntari, reflex del de llibertat de disposar, és establert als articles 367 i 322, que graduen, a més, aquesta prevalença tot respectant el principi de prelació de la successió paccionada sobre la testamentària*".

Encara que aquest text està escrit pensant en les relacions entre la successió voluntària (testamentària o contractual) i la successió intestada, el principi de primacia de la voluntat del testador per sobre de les provisions legals (tret de les legítimes) és un principi informador de tot el CS, que també s'ha de prendre en consideració a l'hora de resoldre les dificultats que planteja la integració de la vocació legal *ex* art. 144 incís 2n CS en el marc de les vocacions voluntàries contingudes en un acte de disposició *mortis causa*.

3.2. L'expressió "*amb dret d'acréixer*" en el testament

Els quatre germans instituïts en el testament de la Sra. Maria P.P. com a hereus s'han de reputar instituïts conjuntament, ja que la seva institució compleix tots els criteris de l'art. 39 CS: estan instituïts en una mateixa clàusula i sense assignació numèrica de parts. Per tant, en els supòsits previstos legalment (art. 38 CS), pot operar entre ells l'acreixement.

En el nostre cas, però, el dret d'acréixer entre els quatre instituïts no opera només a conseqüència de la *coniunctio*, sinó que la pròpia testadora, en instituir hereus als seus quatre fills, va ordenar que s'havien de tenir per instituïts "*amb dret d'acréixer*". Tradicionalment, el dret d'acréixer ha estat concebut com una conseqüència de la crida conjunta de diverses persones a un únic objecte, en el nostre cas, a una única quota hereditària o a una única herència. En ser la crida solidària, si

[3] La frase de BOSCH CAPDEVILA sembla referir-se a qualsevol dels dos casos de l'art. 144 CS, però, al meu judici, és excessiu parlar de què la crida és legal en el cas del testador que institueix genèricament als seus "fills", ja que aquest terme pot tenir en ocasions el sentit genèric de "descendent". Vegeu el Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, Barcelona/Palma/Valencia, 1995, veu "*fill*", on se'ns refereix l'expressió "*fills d'Adam*" per a referir-se a tota la humanitat.

un dels cridats no vol o no pot succeir, es produeix automàticament un increment de la quota que correspon en el dret als cridats conjuntament al mateix objecte. En aquest sentit s'han pronunciat la gran majoria dels juristes medievals i moderns (vegeu CÁNCER (1608), cap. 21 § 54 i BELLONI (1672)), la pandectística vuitcentista (per exemple WINDSCHEID / KIPP (1906) § 603 (p. 465)) i la doctrina més recent (PUIG FERRIOL / ROCA TRIAS (2006, p. 100)).

L'acreixement, per tant, s'ha concebut sempre com un efecte de la vocació conjunta (*coniunctio*), això és, de la crida solidària de diversos a un mateix objecte i no com una via per a designar de forma expressa a qui hagi d'ocupar el lloc de qui ha quedat apartat de la successió (ZIMMERMANN, 1984, pp. 234 i ss.).

No obstant això, la doctrina catalana, sobre la base de l'art. 38 CS, admet de forma unànime que l'acreixement pot operar tant en aquells casos en què el testador ho hagi ordenat tàcitament (instituint a diverses persones conjuntament), com si el testador ho ha concedit de forma expressa, indicant que entre dos o més successors ha d'operar l'acreixement. Aquest seria el cas de les paraules "*amb dret d'acréixer*" que llegim en el testament de la Sra. Maria P.P., que no tindrien un altre sentit que la concessió expressa del dret d'acréixer entre si als quatre hereus instituïts.

3.3. La prelació entre la voluntat testamentària presumpta de l'art. 144.2 CS i l'acreixement ordenat pel testador de forma expressa o tàcita

El punt clau per a resoldre la qüestió que ens ocupa consisteix en fixar un ordre de prelació en l'operativitat de les dues vocacions que acabem d'examinar: d'una banda, la dels descendents de l'instituït premort, que es fonamenta en l'art. 114.2 CS, i, per una altra, la dels beneficiaris de l'acreixement, que, en el nostre cas, són els germans de l'instituït que va morir abans que la testadora.

La solució no és senzilla, ja que no existeix en el CS cap norma que imposi de forma clara la prelació d'un o d'un altre dret a succeir, i menys encara tenint en compte que, en el cas concret que ens ocupa, hi ha un element afegit que s'ha de prendre en consideració: l'acreixement no opera per efecte d'una mera vocació conjunta dels instituïts, sinó que la testadora ho va ordenar expressament. Per això, haurem de fixar amb exactitud la funció que exerceix cadascun dels instituts en conflicte, per a després intentar cercar en els principis generals que informen el nostre Dret la solució més adequada.

a) Sentit i abast de l'expressió "Llevat que aparegui que és una altra la voluntat del testador..." de l'art. 144 CS

L'art. 144 CS s'inicia amb una frase que distingeix de forma clara aquest precepte d'altres normes de Drets espanyols, que també regulen un dret de representació operatiu en el marc de la successió testamentària. Aquesta distinció és fonamental per entendre quins límits va voler donar el legislador català al dret de l'art. 144.2 CS.

L'art. 21 de la Llei aragonesa de Successions (Llei 1/1999 de 24 de febrer - BOA núm. 26, de 4.3.1999[4]) estableix un règim de "substitució legal" que opera *"[s]alvo previsión en contra del disponente..."*, això és, tret que el disposant hagi ordenat expressament una substitució vulgar (SAP Terol, de 7 de juny de 2000, JUR 2000\242042). La llei 309 de la Compilació navarresa (Llei 1/1973, d'1 de març, BOE núm. 57 de 7.3.1973[5]) també estableix un dret de representació que ha d'operar en la successió testamentària *"[a] falta de disposición del causante..."*, una expressió que ha d'interpretar-se també com l'ordenació d'una substitució vulgar expressa.

En canvi, l'art. 144.2 CS opera tan sols *"Llevat que aparegui que és una altra la voluntat del testador..."*, una expressió molt més àmplia que permet modular l'aplicabilitat de l'esmentat article segons les circumstàncies que concorrin en cada cas concret.

L'expressió escollida pel legislador català troba el seu antecedent en les regles interpretatives dels juristes medievals (vegeu, per tots, MANTICA, 1587, lib.1, tit. 2, §§ 1 ss.), que solien cridar *coniecturae legis* a aquestes normes presumptives de la voluntat del testador, l'operativitat de les quals quedava sempre limitada a aquells casos en què no es pogués deduir del testament, encara que fos per via de conjectura, que el testador concret en qüestió no havia tingut la voluntat que li presumia la llei. Aquestes conjectures particulars que deixaven inoperants les conjectures legals solien rebre el nom de *coniecturae hominis*.

Així doncs, perquè l'art. 144.2 CS quedi inoperant, no és imprescindible que el testador ho hagi establert així expressament, sinó que basta que del tenor del testament es desprengui que el testador no va voler que els descendents del fill premort succeïssin en el seu lloc. Per això l'art. 144.2 CS queda inoperatiu de forma automàtica en casos en què el testador ha designat expressament a qui vol que correspongui la successió en cas de vacança d'una quota.

Però és més: encara que el testador no hagués concedit expressament als instituïts el dret d'acréixer, pel mer fet d'haver estat instituïts conjuntament, quedaven ja tàcitament exclosos els descendents del fill premort, ja que resulta aparent *"...que és una altra la voluntat del testador"*. Només en el cas que no aparegui manifestada (expressa o tàcitament) la voluntat del testador podrà operar la delació de l'herència prevista en l'art. 144.2 CS.

---

[4] El tenor d'aquest art. 21 és: *"Sucesiones voluntarias. 1. En las sucesiones voluntarias la sustitución legal tiene lugar cuando el llamado ha premuerto o ha sido declarado ausente o indigno de suceder.*
2. La sustitución legal se produce en favor de los descendientes, sin limitación de grado, del sustituido que a su vez sea descendiente o hermano del causante.
3. Los sustitutos que reciban la porción del llamado a la herencia declarado ausente deberán cumplir las obligaciones que impone la normativa sobre la ausencia".
Aquesta norma recull, en essència, el tenor del derogat art. 141 de la Compilació aragonesa.

[5] El tenor de la Llei 390 és: *"Cuándo procede. El derecho de representación se dará siempre que lo hubiere establecido el causante, quien podrá también excluirlo en cualquier caso.*
A falta de disposición del causante, el derecho de representación se dará, tanto en la sucesión legal como en la voluntaria, a favor de sus descendientes sin limitación, y a favor de los descendientes de sus hermanos hasta el cuarto grado a contar del propio causante".

L'afer de la preferència entre l'art. 144.2 CS i l'acreixement entre els qui han estat instituïts conjuntament (sense que el testador els hagi atribuït expressament el dret d'acréixer) no afecta directament el testament de la Sra. Maria P.P., en el que hi ha una atribució expressa, però ha de ser examinat amb detall perquè constitueix un sòlid argument *a fortiori*.

b) L'art. 144.2 CS i l'acreixement entre hereus instituïts conjuntament

Fins que es va plantejar el cas que ens ocupa, els Tribunals no s'havien pronunciat sobre el problema de si la vocació *ex lege* que neix de l'art. 144.2 CS ha d'operar amb preferència a l'acreixement o viceversa. No obstant, la sentència del TSJ de Catalunya de 25 de gener de 2001 (RJ 2001\8171), dictada en un cas en què resultava aplicable la Compilació, estableix una doctrina que, al meu parer, continua sent aplicable en el marc normatiu del CS: l'acreixement entre hereus instituïts conjuntament ha d'operar per davant d'una voluntat testamentària que merament pot presumir-se sobre la base d'elements externs al testament (en aquell cas, una nota manuscrita per la testadora), però que no té cap referent en el text testamentari.

La primacia de la voluntat manifesta del testador enfront de la voluntat presumpta per la llei té una llarguíssima tradició en la jurisprudència europea, per influència, sobretot, de la romanística (p.ex. BELLONI (1672), cap. 10, quaest.21, p. 231). A Catalunya, aquest principi fou defensat per CÁNCER (1608) en el segle XVI (part 3a, cap. 12, § 145) i per l'humanista FINESTRES (1752) en el segle XVIII (p. 216), amb la qual cosa es va convertir en un dels pilars del Dret successori català, que s'enunciava generalment amb el brocard: "*dispositio hominis facit cessare provisionem Legis*" ("la disposició de l'home deixa ineficaç la provisió de la Llei"). Ja en el segle XX, BORRELL I SOLER 1944, § 450 (p. 96) va reconèixer la importància d'aquest principi com a part integrant del Dret català i el mateix pot dir-se de la doctrina posterior a l'aprovació de la Compilació i del CS (es pot consultar, per tots, PUIG FERRIOL / ROCA TRIAS, 2006, pp. 215 i ss.).

En el cas concret que ens ocupa, aquesta doctrina implica que l'acreixement ha de ser preferent a la vocació *ex lege* de l'art. 144.2 CS, la qual opera, al seu torn, amb preferència enfront de l'anomenat increment successori (art. 41 CS), que és un mer efecte legal que no es funda en una voluntat, expressa o tàcita, del disposador.

L'acreixement opera per davant de la vocació *ex* art. 144.2 CS en tot cas, però aquesta prelació és encara més clara en aquells casos en què, com el que ens ocupa, *l'ius adcrescendi* ha estat concedit expressament pel testador. Si, en el cas d'hereus instituïts conjuntament, l'acreixement compta amb la legitimació de la voluntat tàcita del causant, en aquells casos en què el dret d'acréixer s'hagi concedit expressament, el titular del dret d'acréixer compta amb una crida explícita del disposant.

Per tot això, no podem compartir la tesi de BOSCH CAPDEVILA (2002 pp. 275 i ss), segons la qual els representants cridats en aplicació de l'art. 144 CS haurien de tenir un dret preferent al dels titulars d'un dret a acréixer, per aplicació analògica de l'art. 327.2 CS.

L'aplicació analògica de l'art. 327.2 CS no és possible al meu entendre perquè la dicotomia dret de representació (*ex* art. 328 CS)-acreixement (*ex* art. 327.1 CS), que trobem en la successió intestada, té una *ràtio* subjacent completament diferent de la que està darrera el binomi dret de representació testamentari (*ex* art. 144 CS)-acreixement entre successors vocats conjuntament (*ex* arts. 38 i ss. CS).

L'ordre de la successió intestada consisteix, en els fons, en una presumpció de la voluntat del testador[6]. Tant els cridats per via d'acreixement com per dret de representació són vocats perquè la llei presumeix que el testador-tipus els hauria volgut com a successors i, en establir una jerarquia entre ells, la llei no fa una altra cosa que col·locar primer a aquells que presumeix que un testador-tipus hauria col·locat en primer lloc, i col·locar desprès a aquells que el testador presumiblement hauria volgut al darrere. Per això l'art. 327.2 CS dóna preferència als cridats per dret de representació enfront dels cridats per via d'acreixement: la Llei presumeix que el testador va voler que li succeïssin els seus néts, abans que ampliar la quota que correspon als seus fills.

En la successió testamentària, en canvi, regeix el principi de respecte a la voluntat expressada pel testador, que preval sobre aquella que la llei pugui presumir; per tant, allò expressat pel testador haurà de prevaldre sobre la voluntat tàcita i, amb més raó encara, sobre la voluntat presumpta.

Així doncs, res obsta a què el dret de representació testamentari de l'art. 144 CS hagi d'operar amb preferència a l'increment successori necessari (art. 41 CS) ja que, ambdós instituts responen a una presumpció *ex lege* de la voluntat del testador i, per tant, entre ells hi ha una relació anàloga a la que hi ha entre el dret de representació i l'acreixement en la successió intestada. Però no és acceptable que la presumpció legal de l'art. 144 CS hagi de primar per sobre de la voluntat tàcita del testador que subjeu en el dret d'acréixer entre successors instituïts conjuntament, i, molt menys encara, que passi per davant de la voluntat expressa del testador, que existeix quan aquest ordena explícitament l'operativitat del dret d'acréixer entre dos o més successors.

Aquesta tesi troba, a més, un fort suport legal a tenor de l'art. 38.3 CS: quan es fa referència als que tenen un dret a succeir preferent a l'acreixement s'indica el transmissari, el substitut vulgar i el substitut fideïcomissari, però no es fa cap referència al dret de representació introduït *ex lege* per l'art. 144 CS.

Per l'últim, cal subratllar que, fins i tot si es considerés que els cridats ex art. 144 CS no ho són en tant que titulars d'un dret de representació, sinó com a substituts vulgars, tampoc succeirien amb preferència a l'acreixement, encara que en aquest cas cal admetre que el tenor literal de l'art. 38.3

[6] Alguns autors recents (PUIG FERRIOL / ROCA TRIAS, 2006, p. 501) han defensat que la vocació legal no es basa en la presumpció de la voluntat del causant sinó que té el seu fonament en l'interés que té la llei en que tothom tingui un successor. Aquesta afirmació és inexacta des del punt de vista històrico-jurídic i s'ha d'entendre pronunciada, més que res, amb la finalitat de que no es pugui intentar alterar l'ordre successori *ab intestato* per la via de demostrar la prioritat en els afectes del causant.

CS representa un obstacle important. Jo penso, de totes maneres, que quan l'art. 38.3 CS diu que la substitució vulgar ha d'operar per davant de l'acreixement està pensant en la contraposició d'una crida expressa (substitució vulgar), amb la que dóna preferència enfront d'una tàcita (acreixement *inter coniunctos*) –sobre aquest punt, vegeu HILLIGER (1841, p. 495, n.5)– ; però si contraposem una voluntat presumpta (crida *ex* art. 144, oració 2a, CS) a una tàcita (acreixement *inter coniunctos*), ha de prevaler en tot cas la tàcita, ja que, sense comptar amb l'expressa referència del testador, almenys es pot induir de les paraules escollides per ell a l'hora de testar.

En contra d'aquesta tesi, BOSCH CAPDEVILA (2002, pp. 254 i ss.) sosté que, si es considera que la successió *ex* art. 144 CS té lloc per substitució vulgar tàcita, l'art. 38.3 CS implicaria que els substituts succeirien amb preferència als titulars d'un dret d'acréixer. Aquesta postura és difícil de conciliar amb les tesis defensades pel propi autor unes pàgines abans, quan, parlant de les substitucions vulgars tàcites, manifesta "*cal analitzar un per un els supòsits que poden donar origen a aquestes substitucions tàcites, però podem adelantar que la naturalesa d'aquests supòsits fa més adient una interpretació restrictiva de l'art. 38.3 CS*". No és fàcil entendre per què l'art. 38.3 CS s'ha d'interpretar restrictivament en relació amb les substitucions vulgars tàcites i, en canvi, en el cas de l'art. 144 CS, que conté una substitució vulgar presumpta, aquesta mateixa norma s'ha d'interpretar extensivament.

Al meu parer, en l'actualitat mantenen tot el seu vigor les paraules que BELLONI (1672, cap. 10, *quaest*. 21, n. 43) va escriure al principi del segle XVII en relació amb el problema que ens ocupa (traduïm del llatí[7]):

> "Sens dubte, de vegades no s'aplica el que acabem de dir i la substitució no exclou el dret d'acréixer: en primer lloc, si consta per conjectures que aquesta era la voluntat del testador, no es deferirà al substitut la part vacant, sinó a l'instituït conjuntament [...] ja que, segons la voluntat del testador, l'instituït conjuntament té preferència enfront del substitut [...] tant si aquesta voluntat és expressa com si és tàcita."

En relació amb el vigent art. 38.3 CS la tesi de BELLONI implica que aquesta norma només es pot aplicar estrictament als casos de substitució vulgar ordenada expressament, perquè aquest és el cas en què s'estava pensant en redactar el precepte[8]. En els casos de substitució vulgar tàcita o

---

[7] "*Plane interdum supradicta cessant et substitutio non excludit ius accrescendi. Primum enim si ex coniecturis constet talem esse voluntatem testatoris non admittetur ad partem vacantem substitutus sed coniunctus* [...] *Nam ex voluntate defuncti coniunctus substituto praeferut [...] sive voluntas sit expressa vel tacita ...*".

[8] Aquest sembla ser l'abast que donen al precepte LL. PUIG FERRIOL, y E. ROCA TRÍAS (2006, p. 103) quan afirmen: "El testador pot preveure la manca de l'hereu; per això l'art. 38.3 CS estableix que quan en lloc de l'hereu que falta arribi a ser-ho algun del seus hereus per dret de transmissió successòria o ho esdevenen els cridats per via de substitució vulgar o per fideïcomís, no té lloc el dret d'acréixer perquè, com ja s'ha dit abans, el dret d'acréixer és sempre voluntari per al causant"-

presumpta, excepte puntuals excepcions[9], ha de resultar preferent el dret d'acréixer, tant si ha estat ordenat expressament pel testador, com si es desprèn tàcitament a partir d'una crida conjunta.

c) L'art. 144.2 CS i l'acreixement entre hereus als quals el testador ha atribuït expressament el *ius adcrescendi*

La preferència del dret d'acréixer dels cridats conjuntament a l'herència enfront d'aquelles persones que només poden fundar el seu dret a succeir en una crida presumpta és encara més clara si l'acreixement no es dedueix tàcitament de la crida conjunta, sinó que ha estat expressament atribuït pel testador.

No és que l'atribució expressa del dret d'acréixer confereixi als seus beneficiaris un dret diferent del que tenen els instituïts conjuntament, sinó que el que ocorre és que la concessió expressa de l'acreixement revesteix els seus beneficiaris amb la legitimitat que comporta haver estat cridat expressament i clarament pel testador i els situa per davant de qualsevol persona que pugui al·legar un dret successori que es fundi tan sols sobre una voluntat tàcita o presumpta del disposador.

Així doncs, si el testador ha concedit expressament el dret d'acréixer, aquest dret operarà amb preferència a una substitució vulgar tàcita, al dret de representació de l'art. 144.2 CS i fins i tot enfront d'un acreixement entre hereus que simplement hagin estat instituïts conjuntament: per exemple, si un testador institueix a tres persones amb els termes "A i B siguin hereus d'una meitat; C sigui hereu d'una altra meitat, amb dret a acréixer la part de B" és evident que, si B deixa vacant la seva quota, primer es deferirà a C en virtut del dret d'acréixer ordenat expressament i, només si aquest no vol o no pot succeir, operarà el dret d'acréixer entre hereus instituïts conjuntament (fundat en una voluntat tàcita del testador) i es deferirà l'herència a A.

En conclusió, doncs, si el testador ha concedit expressament el dret d'acréixer, només tindran preferència en la successió aquelles persones que fundin el seu dret en una crida expressa del causant (per exemple, per mitjà d'una substitució vulgar expressa), però mai aquells que només puguin al·legar a favor seu una voluntat tàcita o presumpta del disposant.

La conclusió a què ens han conduït les argumentacions de caràcter dogmàtic es veuen corroborades, pel testament concret de la Sra. Maria P.P., amb el resultat d'una adequada exegesi del testament, fundada en els elements intrínsecs de prova de la voluntat testamentària. La clàusula més rellevant del testament, als efectes d'interpretar la institució d'hereu, és el dret d'adquisició preferent ordenat per la testadora en la clàusula segona a favor dels cohereus, pel cas que algun d'ells vengués la seva part sobre la finca rústica que constituïa l'únic bé de l'haver hereditari. Sembla clar que la testadora tenia interès a evitar que, un cop adquirida la finca pels

[9] Les excepcions que accepta BOSCH CAPDEVILA (2002, pp. 255 i ss.) són les de qui és cridat com substitut vulgar en virtut d'una substitució tàcita inclosa en una fideïcomissària expressa.

hereus, alguns d'ells optessin per vendre la seva part a qui més els oferís per ella, cosa que provocaria una ràpida disgregació de l'explotació agrícola, en perjudici de la seva rendibilitat.

És obvi que la testadora no va voler posar la unitat de la finca per davant de qualsevol altra consideració, ja que, en aquest cas, hauria optat per instituir un únic hereu, seguint un costum molt arrelat a les zones rurals de Catalunya. La testadora no va voler deixar fora de la seva herència a cap dels seus quatre fills, potser per no agreujar-los o per no deixar-los desprotegits en la seva vellesa. Però mitjançant l'ordenació d'un dret d'acréixer i d'un dret d'adquisició preferent la causant va voler posar els mitjans perquè la propietat de la finca tendís a concentrar-se en poques mans, de manera que no acabés disgregada.

El mitjà elegit sembla bastant idoni: segons el parer de molts experts, l'origen del dret d'acréixer en la fosca època arcaica de la història romana va tenir el seu origen, precisament, en la necessitat mantenir les explotacions agropecuàries unides perquè resultessin viables (M. KASER, 1971 p. 667). Certament, el nostre dret posava a disposició de la testadora altres mitjans més radicals per aconseguir la seva finalitat, entre ells, per exemple, l'ordenació d'una substitució fideïcomissària recíproca entre els cohereus. El problema d'aquest expedient, no obstant això, és el seu alt cost fiscal en l'Impost de Successions, perquè implica que, en un termini breu de temps, es produiran diverses successions entre parents col·laterals, cadascuna d'elles gravada per l'impost.

En definitiva, fa la impressió que la testadora va adoptar una actitud possibilista i que va elegir la solució que li permetia compaginar el seu desig de no deixar fora de l'herència a cap dels fills que la sobrevisqués (tots ells d'edat avançada) i la seva voluntat de comprometre el mínim possible la unitat de la seva casa pairal.

4. Conclusions

A manera de conclusió pot dir-se, perquè, que el dret d'acréixer conferit expressament per la testadora ("amb dret d'acréixer") als cohereus de l'instituït premort ha d'operar amb preferència a la vocació *ex lege* dels néts del testador ex art. 144.2 CS per les raons següents:

> 1) El dret d'acréixer entre hereus instituïts conjuntament opera, en tot cas, de manera preferent a la vocació presumpta de l'art. 144.2 CS; la raó és que l'acreixement entre hereus instituïts conjuntament es fonamenta en una crida tàcita del testador (*coniunctio*), mentre que la successió *ex* art. 144.2 CS té la seva base tan sols en una voluntat presumpta, establida *ex lege*, que ha d'operar únicament "Llevat que aparegui que és una altra la voluntat del testador...". La mera crida conjunta a succeir s'ha de considerar, per tant, una aparença suficient de la voluntat del testador com per donar preferència als així cridats enfront de la vocació legal *ex* art. 144.2 CS.
>
> 2) En els casos en què el dret d'acréixer hagi estat concedit expressament pel testador, encara amb més raó serà preferent l'acreixement enfront de la successió *ex* art. 144.2 CS, ja

que els cohereus que han d'acréixer compten amb la legitimitat d'haver estat cridats expressament pel causant, mentre que la crida *ex* art. 144.2 CS es fonamenta tan sols una hipotètica voluntat del testador que la llei presumeix.

A més, la vocació *ex* art. 144.2 CS és legal (*ex lege*), no voluntària (*ex* testament). És la llei i no el testament qui crida a succeir als néts del testador, que no apareixen en el testament ni tan sols de manera tàcita. Per tant, el principi de primacia de la crida voluntària enfront del legal que regeix en el CS (Preàmbul, ap. II) comporta que el dret de les persones que han rebut la vocació expressament pel testador hagi de prevaler enfront d'aquelles que l'han rebuda per la llei.

Aquesta conclusió val tant si es qualifica la successió *ex* art. 144.2 CS com a dret de representació com si es veu com una substitució vulgar. Si, conforme a l'opinió majoritària, considerem que el referit article preveu un dret de representació operatiu en la successió testamentària, aquest dret de representació no podrà operar igual que en la successió intestada, ja que en aquest últim àmbit totes les vocacions són legals i es funden en la voluntat presumpta del testador, mentre que en la successió testamentària hi ha una voluntat manifesta (expressa o tàcita) que ha de ser sempre preferent enfront de la successió legal, basada en meres presumpcions dels desitjos del causant. Per això l'art. 367 CS no és aplicable per analogia al nostre cas, ja que no concorre el requisit d'idèntica ràtio, imprescindible per estendre l'aplicació de les normes per analogia.

3) D'altra banda, encara que qualifiquéssim de substitució vulgar presumpta la successió *ex* art. 144.2 CS, tampoc tindrien aquests "substituts vulgars" un dret a succeir preferent a l'acreixement dels cohereus instituïts "amb dret d'acréixer" conjuntament amb el fill premort: l'art. 38.3 no resultaria aplicable a aquest cas, ja que la raó per la qual aquesta norma dóna preferència al substitut vulgar enfront de l'acreixement és que la substitució recull la voluntat expressa del testador, mentre que l'acreixement entre hereus instituïts conjuntament només es funda en una voluntat tàcita. En el cas que ens ocupa, al contrari, qui compta amb la legitimitat d'haver estat vocat expressament no són els "substituts vulgars" (que ni tan sols apareixen en el testament) sinó els cridats a acréixer, als que els va ser concedit aquest dret per disposició expressa de la testadora. Per això, el dret a succeir d'aquests últims s'ha de reputar preferent.

5. *Apèndix: les novetats en la regulació del problema en el Llibre Quart del Codi Civil de Catalunya*

El dia 18 de juny de 2008, mentre s'ultimava la revisió del present article, el Parlament de Catalunya va aprovar el llibre quart del Codi civil de Catalunya relatiu a les successions. En el punt que ens ocupa, el nou text segueix en la línia de la regulació anterior, encara que introdueix algunes novetats d'especial importància que no poden deixar de comentar-se encara que sigui en la forma d'un breu apèndix.

L'art. 423-8 del CCC inclou una regla similar a la de l'art. 144.2 del CS, segons la qual, si el testador que institueix als seus fills per parts iguals i de forma nominativa, es confereix als descendents de l'instituït un dret de representació. No obstant això, en el CCC aquest dret no es limita expressament al cas de premoriència del fill instituït, de manera que, previsiblement es plantejarà el dubte sobre si resulta aplicable, per analogia amb l'art. 441-7 CCC, també en cas de declaració d'absència o d'indignitat. La resposta possiblement hagi de ser afirmativa.

Concretament, pel que fa al problema que estem analitzant en el present treball, l'art. 462-1 CCC (a diferència del que succeïa en l'art. 38.3 CS) estableix expressament que el dret de representació en la successió testada serà preferent a l'acreixement. Aquest posicionament del legislador impedeix propugnar sota el nou text legal que l'acreixement entre instituïts conjuntament ha de ser preferent al dret de representació. Per tant, l'enfocament oposat que s'ha defensat anteriorment queda exclòs en aquells testaments a què resulti aplicable el nou règim jurídic (Disp. Trans. 2a). No obstant això, la doctrina de la citada STSJ Catalunya de 26.7.2007 continua sent aplicable si el testador ha ordenat expressament l'acreixement, ja que, per pròpia disposició legal, el dret de representació només opera en la successió testada "Llevat que s'infereixi que la voluntat del testador és una altra…" (art. 423-8 CCC). Per consegüent, el cas de la successió de la Sra. Maria P. P. hauria tingut idèntica solució si s'hagués plantejat sota la nova regulació.

6. *Jurisprudència citada*

Tribunal, Sala i Data	*Ar.*	*Magistrat Ponent*	*Parts*
SAP Teruel 7.6.2000	JUR 2000\242042	José Antonio Ochoa Fernández	*Francisco Julián P.F. i Manuel P.F. c. Joaquín P. R. i Carmen S.G.*
STSJ Cataluña 25.1.2001	RJ 2001\8171	Lluís Puig Ferriol	*Adrià Ll. S.* c. *Antonio i Adrià T. Ll*
SAP Barcelona (Civil Sec. 1a) 10.10.2006	JUR 2007\145197	Josep Llobet Aguado	*José María F.P., Núria F.P. i Luis Ignacio F.P. c. Maria Rosa F.P., Núria F.P, Juan F.P., Cristina R. F. i Manuel Alejandro V.-L. E.*

7. *Bibliografia*

Dominik van ARUM (1620), *Disputationes ad praecipuas Pandectarum et Codicis leges, Consuetudines Feudales, quattuor Institutionum libros*, Jena.

Antonio BELLONI (1672), *De iure accrescendi tractatus*, Venècia.

Antonio María BORRELL Y SOLER (1944), *Derecho civil vigente en Cataluña*, vol. 5, Editorial Bosch, Barcelona.

Esteve BOSCH CAPDEVILA (2002), *L'acreixement en el Dret successori català*, Departament de Justícia,

Barcelona.

Paul BUSIO (1656), *Commentarius in universas Pandectas Domini Iustiniani cum differentiis consuetudinum communium et Germaniae, Galliae, Belgicae singularium itemque iuris canonici*, Deventer.

Adolfo CALATAYUD SIERRA (1994), "Comentario a los arts. 167 y 169 CS", en Lluís JOU MIRABENT (Director), *Comentarios al Código de Sucesiones de Cataluña*, vol. I, Bosch, Barcelona.

Jaume CÁNCER (1608) (= Jacobus CANCERIUS), *Variarum resolutionum iuris Caesarei, Pontificii et Municipalis Principatus Cathaloniae*, 3ª part, Barcelona.

Jacobo CUYACIO (1758) (= Jacobus CUIACIUS / Jacques CUYAS), *Commentaria in libros responsorum Aemilii Papiniani* en *Opera omnia*, vol. 4, Nàpols.

Josep FINESTRES I DE MONSALVO (1752), *Praelectiones cervarienses sive commentarii academici ad titulos Pandectarum "De inofficioso testamento" ac "De vulgari et pupillari substitutione"*, Cervera.

Antonio GÓMEZ (1768), *Variae resolutiones Iuris Civilis, Communis et Regii*, Madrid.

Otto HILLIGER (1841), notas a H. DONELLO, *Opera omnia commentariorum de iure civili*, vol. 2, Florència.

Max KASER (1971), *Das Römische Privatrecht*, vol. 1, 2ª ed., Beck, Munic.

Francesco MANTICA (1587), *Tractatus de coniecturis ultimarum voluntatum*, Venècia.

Lluís PUIG FERRIOL / Encarna ROCA TRIAS (2006), *Institucions del Dret civil de Catalunya*. Vol. 3 (*Dret de successions*), 6ª ed., Tirant lo Blanc, Valencia.

Joan RUBIES MALLOL (1994), Comentario al art. 144 CS en Lluís JOU MIRABENT (Director) *Comentarios al Código de Sucesiones de Cataluña*, vol. I, Bosch, Barcelona.

Christian THOMASIUS (1766), notas a Ulrich HUBER, *Praelectionum iuris civilis tomi tres secundum Institutiones et Digesta Iustiniani*, Lovaina.

Bernhard WINDSCHEID / Theodor KIPP (1906), *Lehrbuch des Pandektenrechts*, vol 3er (9a. ed.), Frankfurt am Main.

Reinhardt ZIMMERMANN (1984), "Coniunctio verbis tantum", *Zeitschrift der Savigny-Stiftung* (Rom. Abt.) 101.

Hendrik ZOES (1718), *Commentarius ad Digestorum seu Pandectarum iuris civilis libros L*, Lovaina.